

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4147/2550

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดชัยบุรี

โจทก์

นางปราณี นามวงศ์ กับพวก

โจทก์ร่วม

นายเฉลิม พรหมเลิศ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 312 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติให้ผู้กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนมีความผิดโดยไม่คำนึงถึงว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ แต่หากเด็กหญิงนั้นยินยอมก็มีได้หมายความว่า เด็กหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย เมื่อเด็กหญิงถูกกระทำชำเรา แม้เด็กหญิงจะยินยอมก็เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมย่อมมีอำนาจจัดการแทนเด็กหญิง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 5 (1) และมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 3 (2)

จำเลยโทรศัพท์นัดหมายให้ ส. พาเพื่อนไปขายบริการทางเพศแก่จำเลย ส. จึงชักชวนเด็กหญิงทั้งสามอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปกระทำการดังกล่าวแล้วจำเลยรับตัวเด็กหญิงทั้งสามไว้กระทำชำเราโดยเด็กหญิงทั้งสามยินยอมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 5 และที่ 3 โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร แต่การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการรับไว้หรือล่อไปซึ่งเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยทุจริต เพราะจำเลยมิได้รับเด็กหญิงทั้งสามไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องจากจำเลยมีเจตนา

ประสงค์จะกระทำชำเราเด็กหญิงทั้งสามเท่านั้น ไม่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 312 ตี วรรคสอง

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณารวมกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1044/2544 ของศาลชั้นต้น แต่คดีสำนวนดังกล่าวยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 เวลากลางวัน จำเลยกับนางสาว ส. ซึ่งแยกไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกันพรากเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนางปราณี นามวงศ์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และโดยทุจริต ล่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ด. โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมร่วมกันพรากเด็กหญิง อ. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนายคมสันต์ สว่างภพ ผู้เสียหายที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และโดยทุจริต ล่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง อ. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันล่อไปหรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้กระทำการค้าประเวณีโดยเด็กนั้นยินยอม และจำเลยกระทำชำเราเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นยินยอม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 เวลากลางวัน จำเลยกับนางสาว ส. ร่วมกันพรากเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร และโดยทุจริตล่อไปหรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ด. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันพรากเด็กหญิง อ. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และโดยทุจริต ล่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง อ. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วม

กันล่อไปหรือชักพาไปซึ่งเด็กหญิง อ. อายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้กระทำการค้า
ประเวณีโดยเด็กนั้นยินยอม และจำเลยกระทำซ้ำเราเด็กหญิง อ. อายุยังไม่เกิน 15 ปี
ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นยินยอม วันที่ 22 ธันวาคม 2543 เวลากลางวัน
จำเลยกับนางสาว ส. ร่วมกันพราศเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้เสีย
หายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และโดยทุจริต
ต่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ด. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันพราศเด็กหญิง ส. อายุ
ยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนางราตรี จรจิต ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นมารดาโดย
ปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และโดยทุจริต ล่อไปหรือพาไปซึ่งเด็กหญิง
ส. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันพราศนางสาว อ. ผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน
18 ปี ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอัน
สมควรเพื่อการอนาจารและโดยทุจริต ล่อไป หรือพาไปซึ่งนางสาว อ. โดยบุคคลนั้น
ยินยอมร่วมกันล่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้กระทำ
การค้าประเวณีโดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันล่อไป หรือชักพาไปซึ่งเด็กหญิง ส. อายุยัง
ไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้กระทำการค้าประเวณีโดยเด็กนั้นยินยอม จำเลยกระทำซ้ำเรา
เด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นยินยอม และ
วันที่ 3 มกราคม 2544 เวลากลางวัน จำเลยกับนางสาว ส. ร่วมกันพราศเด็กหญิง ด.
อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดา โดยปราศจากเหตุอัน
สมควร และโดยทุจริตล่อไป หรือพาไป ซึ่งเด็กหญิง ด. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกัน
พราศเด็กหญิง ส. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นมารดาโดย
ปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร และโดยทุจริต ล่อไป หรือพาไปซึ่งเด็กหญิง
ส. โดยเด็กนั้นยินยอม ร่วมกันล่อไปหรือพาไปซึ่งเด็กหญิง ส. อายุยังไม่เกิน 15 ปี
เพื่อให้กระทำการค้าประเวณี โดยเด็กนั้นยินยอม และจำเลยกระทำซ้ำเราเด็กหญิง ส.
อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นยินยอมขอให้ลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 277, 312 ตร., 317, 319 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น นางปราณี นามวงศ์ มารดาเด็กหญิง ด.
นางราตรี จรจิต มารดาเด็กหญิง ส. นายคมสันต์ สว่างภาพ ผู้ปกครองเด็กหญิง อ.
และนางศรีสุด สว่างภาพ มารดาเด็กหญิง อ. ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้นางปราณี นางราตรีและนายคมสันต์เข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะข้อหา
กระทำชำเรา และความผิดต่อเสรีภาพ ส่วนนางศรีสุดเข้าร่วมเป็นโจทก์เฉพาะข้อหา
กระทำชำเราเด็กหญิง อ. โดยเรียกผู้ร้องดังกล่าวเป็นโจทก์ร่วมที่ 2 ถึงที่ 5 ตาม
ลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคแรก จำคุกกระหนงละ 4 ปี รวม 4 กระหนง จำคุก 16 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์ โจทก์ร่วมที่ 2 ถึงที่ 5 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 312 ตร. วรรคสอง, 317 วรรคสาม ด้วย ฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการ
อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม จำคุกกระหนงละ 5 ปี
รวม 4 กระหนง จำคุก 20 ปี สำหรับความผิดฐานกระทำชำเราตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคแรก และฐานโดยทุจริต ล่องไป หรือพาไปซึ่งเด็กตามมาตรา
312 ตร. วรรคสอง เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐาน
กระทำชำเราตามมาตรา 277 วรรคแรก ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก กระหนงละ 4 ปี รวม 4 กระหนง เป็นจำคุก

16 ปี รวมจำคุก 36 ปี ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้โจทก์ร่วมที่ 4 เข้าร่วมเป็นโจทก์ในข้อหากระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุ เด็กหญิง ด. มีอายุ 13 ปีเศษ เป็นบุตรโจทก์ร่วมที่ 2 เด็กหญิง ส. มีอายุ 14 ปีเศษ เป็นบุตรโจทก์ร่วมที่ 3 และเด็กหญิง อ. มีอายุ 14 ปีเศษ เป็นบุตรโจทก์ร่วมที่ 5 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า โจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก หรือไม่ เห็นว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้ผู้กระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้กริยาของตนนั้นมีความผิดโดยไม่คำนึงว่าเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่หากเด็กหญิงนั้นยินยอมก็มีได้หมายความว่า เด็กหญิงนั้นมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย เมื่อเด็กหญิง ด. เด็กหญิง ส. และเด็กหญิง อ. ถูกกระทำชำเราแม้เด็กหญิงทั้งสามจะยินยอมก็เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิดข้อหานี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) โจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมย่อมมีอำนาจจัดการแทนเด็กหญิง ด. เด็กหญิง ส. และเด็กหญิง อ. ตามลำดับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (1) และมีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในความผิดข้อหานี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 (2) คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างในฎีกานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 หรือไม่... พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ โจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยโทรศัพท์นัดหมายให้นางสาว ส. พาเพื่อนไปขายบริการทางเพศแก่จำเลย นางสาว ส. จึงชักชวนเด็กหญิง ด. เด็กหญิง อ. และเด็กหญิง ส. ไปกระทำการดังกล่าว แล้วจำเลยรับตัวเด็กหญิงทั้งสามไว้กระทำชำเราโดยเด็กหญิงทั้งสามยินยอมที่โรงแรมผกาอินท์ เป็นการล่วงอำนาจปกครองของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่ 5 และที่ 3 ตามลำดับ โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำชำเราเด็กหญิง ด. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตน และพราบดีกหญิง ด. โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 กระทำชำเราเด็กหญิง อ. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตน และพราบดีกหญิง อ. โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2543 และกระทำชำเราเด็กหญิง ส. อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตน และพราบดีกหญิง ส. โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2543 และวันที่ 3 มกราคม 2544 แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวมิใช่เป็นการรับไว้หรือล่อไปซึ่งเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยทุจริต เพราะจำเลยหาได้รับเด็กหญิงทั้งสามไว้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาประสงค์จะกระทำชำเราเด็กหญิงทั้งสามเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ตรี วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดดังกล่าวมาด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ตรี วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(เรวัตร์ อิศราภรณ์-ประทีป ชุ่มวัฒนะ-วีระชาติ เอี่ยมประไพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้มาเป็นเวลานานแล้วว่าผู้ที่ยินยอมให้มีการกระทำความผิด มิใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) เช่นฎีกาที่ 968/2479, 1183/2480 และ 643/2486 ซึ่งวินิจฉัยตรงกันว่าผู้ที่ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ เกินอัตราตามกฎหมายมิใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งผู้ให้กู้เป็นผู้กระทำความผิด ในประเด็นเรื่องความรับผิดในทางอาญาของ "ผู้กู้" ต้องถือว่าผู้กู้ไม่มีความผิดอาญาใด ๆ เลยในความผิดของผู้ให้กู้ดังกล่าว แม้ผู้กู้จะเป็นผู้เสนอดอกเบี้ยที่เกินอัตราแก่ผู้ให้กู้ ผู้กู้ก็ไม่อาจเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดดังกล่าวของผู้ให้กู้ เพราะมีหลักในเรื่องความรับผิดทางอาญาว่า กฎหมายมาตราใดบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลใด บุคคลนั้นจะเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดตามมาตรานั้น ๆ ไม่ได้แม้ว่าตนจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ๆ เพียงใดก็ตาม ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กู้แม้ผู้กู้จะยินยอมให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งการกระทำของผู้ให้กู้เป็นความผิด แต่ผู้กู้ไม่อาจจะเป็น "ตัวการ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้สนับสนุน" ในความผิดดังกล่าวของผู้ให้กู้ได้เลย เพราะกฎหมายนี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กู้ มีข้อสังเกตว่าหลักดังกล่าวเป็นกรณี "ความรับผิดในทางอาญา" ของผู้กู้ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับ

กรณี "ความเป็นผู้เสียหายของผู้ถู" เพราะมีความหมายต่างกัน การที่ผู้ถูไม่มีความผิดใด ๆ ร่วมกับผู้ให้ถูเป็นคนละกรณีกับความเป็น "ผู้เสียหาย" ของผู้ถูในการดำเนินคดีกับผู้ให้ถูในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งศาลฎีกาก็วางบรรทัดฐานในฎีกาที่ 968/2479 ว่า ผู้ถูที่ยอมให้ผู้ให้ถูเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ไม่ใช่ "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรก ตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ก็เช่นเดียวกัน กฎหมายมาตรานี้บัญญัติลงโทษผู้กระทำ เพราะ "ประสงค์จะคุ้มครองผู้ถูกระทำ" ซึ่งอายุไม่เกินสิบห้าปี มิให้ผู้ใดมากระทำความผิดซ้ำเรา ดังนั้นแม้ผู้ถูกระทำจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดสักเพียงใด ผู้ถูกระทำก็ไม่ต้องมีความผิด เช่น เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี จ้างวานชายอายุยี่สิบปีให้มาร่วมประเวณีกับตน ชายผู้กระทำมีความผิดตามมาตรา 277 วรรคแรก แต่เด็กหญิงไม่ต้องมีความผิดใด ๆ เลย ตามมาตรา 277 วรรคแรก แม้การกระทำจะถือได้ว่าเป็นการ "ก่อ" ตาม ป.อ. มาตรา 84 เด็กหญิงก็มีใช่ "ผู้ใช้" ตาม ป.อ. มาตรา 84 ในความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก และเด็กหญิงก็ไม่อาจเป็น "ตัวการ" ตาม ป.อ. มาตรา 83 หรือ "ผู้สนับสนุน" ตาม ป.อ. มาตรา 86 ในการกระทำความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก แต่อย่างใด แม้เด็กหญิงจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำนั้น ๆ เพียงใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะมาตรา 277 วรรคแรก บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีมิให้ผู้ใดกระทำความผิดซ้ำเรา เด็กหญิงจึงไม่อาจเป็น ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดของชายตามมาตรา 277 วรรคแรก ซึ่งกระทำต่อตัวเด็กหญิงนั้นได้ การที่เด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ไม่มีความผิดใด ๆ ในการกระทำความผิดของชาย ตามมาตรา 277 วรรคแรก จึงเป็นคนละประเด็นกับการเป็นผู้เสียหาย มิได้หมายความว่าหากไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบในทางอาญาแล้ว จะกลายเป็นผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาไปได้ทุกกรณี เพราะการที่ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ตั้งแต่ฎีกาที่ 968/2479 ว่า ผู้ถูที่ยอมให้ผู้ให้ถูเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นผู้เสียหายไม่ได้นั้น ศาลฎีกาไม่ได้คำนึงว่า การจะเป็นผู้เสียหายได้หรือ

ไม่ได้ จะต้องพิจารณาว่าผู้กู้มีความผิดทางอาญาใด ๆ ร่วมกับผู้ให้กู้หรือไม่ เพราะแม้ผู้กู้จะไม่มีผิดทางอาญาใด ๆ เลยร่วมกับผู้ให้กู้ ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าผู้กู้ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมาเป็นโจทก์ฟ้องผู้ให้กู้ในความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยในฎีกาที่ 1183/2480 ศาลฎีกาให้เหตุผลว่าเพราะผู้กู้ "ทำสัญญาและชำระดอกเบี้ยโดยสมัครใจ" ซึ่งน่าจะหมายความว่า เมื่อยินยอมให้กระทำความผิดแล้ว จะถือว่าได้รับความเสียหายเพราะการกระทำความผิดนั้นในฐานะเป็นผู้เสียหายได้อย่างไร กรณีตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ หากถือว่าเด็กหญิงซึ่งยินยอมให้ขายร่วมประเวณีโดยสมัครใจ เป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ก็น่าคิดว่าหากนายดำต้องการฆ่าตัวตายจึงจำวานให้นายแดงใช้ปืนยิงตน นายแดงอยากได้เงินค่าจ้างจึงทำตาม แต่ยิงไปแล้วนายดำไม่ตาย นายแดงมีความผิดฐานพยายามฆ่านายดำ เพราะความยินยอมของนายดำดังกล่าวไม่อาจยกเว้นความผิดของนายแดงได้ในความผิดดังกล่าวของนายแดง นายดำไม่ต้องรับผิดใด ๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพราะความผิดฐานฆ่าคนตายบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองชีวิตมนุษย์ซึ่งในที่นี้ คือชีวิตของนายดำ นายดำจึงไม่อาจเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนในความผิดของนายแดงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นคนละประเด็นกับฐานะความเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ของนายดำในความผิดของนายแดงฐานพยายามฆ่านายดำ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือว่านายดำได้รับความเสียหายจากการกระทำของนายแดงในฐานะเป็นผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ที่จะเป็นโจทก์ (หรือกระทำหน้าที่อื่น ๆ ในฐานะผู้เสียหาย ตามที่ ป.วิ.อ. กำหนด) ฟ้องนายแดงในความผิดฐานพยายามฆ่านายดำ หน้าที่ดังกล่าวควรจะเป็นของรัฐโดยพนักงานอัยการเท่านั้นหรือไม่ หรือควรจะให้ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำความผิดต่อตนเอง เช่น กรณีของนายดำตามตัวอย่าง ทำหน้าที่เป็นโจทก์ฟ้องนายแดงได้ในฐานะเป็น "ผู้เสียหาย" ตามความหมายของ ป.วิ.อ. ด้วย นอกเหนือจากพนักงานอัยการอย่างไรก็ตาม กรณีตามฎีกาที่ 4147/2550 นี้ หากจะให้เหตุผลสนับสนุนเพื่อให้เด็ก

หญิงสามารถเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ได้ควรจะต้องอธิบายไปในทำนองที่ว่า เพราะความยินยอมของเด็กหญิงที่ให้ชายร่วมประเวณีกับตน เป็นความยินยอมที่ไม่สมบูรณ์เพราะความเป็นเด็ก ดังนั้นแม้เด็กหญิงจะยินยอมโดยสมัครใจให้ชายร่วมประเวณีกับตน ก็ยังคงต้องถือว่าเด็กหญิง "ได้รับความเสียหาย" (ตามความหมายของผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)) อยู่นั่นเอง เด็กหญิงจึงเป็น "ผู้เสียหาย" ได้ แม้ว่าจะยินยอมโดยสมัครใจให้ชายร่วมประเวณีกับตนก็ตาม ซึ่งความยินยอมของเด็กหญิงดังกล่าวต่างไปจากความยินยอมของผู้กู้ ซึ่งยินยอมให้ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเป็นความยินยอมที่สมบูรณ์ ผู้กู้จึงไม่อาจเป็น "ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4) ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราของผู้ให้กู้ ตามบรรทัดฐานของฎีกาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกียรติขจร วังนะสวัสดิ์